

1500938-58.2021.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE DA FONSECA TAVARES

Comarca: Mirassol

Foro: Foro de Mirassol

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... da droga para restar configurado o crime de tráfico de entorpecente.

Isso porque o crime de tráfico é de perigo abstrato, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci: "o tráfico ilícito de entorpecentes... é um crime de perigo (há uma probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado) abstrato (independe de prova dessa probabilidade de dano, pois presumida pelo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirassol

Foro de Mirassol

2ª Vara

Rua Floriano Peixoto, 1750, Mirassol-SP - cep 15130-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500938-58.2021.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500938-58.2021.8.26.0559

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2179526/2021 - DEL.POL.MIRASSOL, 18850838 - DEL.POL.MIRASSOL, 1634/21/413 - DEL.POL.MIRASSOL, 2179526 - DEL.POL.MIRASSOL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AUGUSTO CASAGRANDE PEREIRA DOS SANTOS

Juiz de Direito: Dr. ANDRE DA FONSECA TAVARES

Vistos.

AUGUSTO CASAGRANDE PEREIRA DOS SANTOS, já qualificado no auto, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput c.c. o artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 02 de julho de 2021, por volta das 23hs46min., na Avenida dos Campos Maia, nº 1530, Vila Moreira, neste Município e Comarca de Mirassol, o acusado trazia consigo, em unidade de designio com o inimputável P.H.M.P., 40 (quarenta) porções de cocaína na forma de "crack" e outras 4 (quatro) porções de cocaína, com pesos líquidos de 4,8 gramas e 2,04 gramas, respectivamente, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar para fins de tráfico ilícito.

A denúncia foi recebida no dia 17 de agosto de 2021. O acusado foi devidamente citado e apresentou defesa preliminar. Houve a manutenção do recebimento da

denúncia.

Houve audiência de Instrução por videoconferência e apresentação de memoriais pelo Ministério Público e pela Defesa.

É o relatório do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Em primeiro lugar, transcrevo o tipo penal indicado na denúncia. Diz o artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06: "Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa".

Transcrevo o artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06: "Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação".

A materialidade do crime restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls.01), pelo Boletim de Ocorrência (fls.16/19), pelo Termo de Depoimento (fls.02, 03), pelo Termo de Declarações (fls.04), pelo Laudo Pericial (fls.26/29, 87/89), pelo Auto de Interrogatório (fls.06), pela Nota de Culpa (fls.09), pelo auto de exibição e apreensão (fls.20/21), pelas fotografias (fls.22/23), pelo Relatório da Autoridade Policial (fls.93/94), bem como pela prova oral produzida.

Passo à análise da autoria.

O policial militar LEONARDO falou na Delegacia que "encontrava-se em patrulhamento, juntamente com o Cb. Bondesan, quando, pelo local dos fatos, avistaram vários indivíduos que, ao verem a viatura, empreenderam fuga a pé. Desembarcou da viatura e perseguiu Augusto, que caiu durante a fuga e acabou por ser capturado. O policial Bondesan fez o cerco com a viatura e logrou deter o menor infrator P. próximo ao local. Em busca pessoal foi localizado com Augusto, R\$ 390,00 (trezentos e noventa Reais) em dinheiro, um celular e uma embalagem contendo 40 pedras de substância aparentando crack e 4 ependorfs contendo substância que aparentava ser cocaína. Também em busca pessoal foi localizado com P., R\$ 80,00 (oitenta Reais) em dinheiro e, em um invólucro plástico, cinquenta e oito pedras de substância aparentando crack. Indagado, Augusto declarou que comercializava a porção de cocaína por R\$ 30,00 (trinta Reais) cada unidade e que vendia cada pedra de crack por R\$ 10,00 (dez Reais). P. narrou que vendia cada porção de crack por R\$ 10,00 (dez Reais). Ambos assumiram que o dinheiro apreendido era proveniente do tráfico. Os indivíduos afirmaram que adquiriram a droga em São José do Rio Preto e que a comercializariam nesta cidade de Mirassol. Os policiais deram voz de prisão ao averiguado Augusto e voz de apreensão ao adolescente, e, ambos foram conduzidos até esta unidade para as providências legais". Em Juízo, confirmou as declarações anteriores.

O policial militar SAMUEL na Delegacia confirmou o depoimento de seu colega de farda Leonardo. Em Juízo, confirmou as declarações anteriores, disse também que "o local era conhecido como ponto de tráfico e o réu conhecido por envolvimento com tráfico, os policiais comentaram que já conheciam ele".

A testemunha de defesa P.H, falou na Delegacia que "encontrava-se na avenida próximo aos "Predinhos", nessa cidade, quando viu alguns meninos correndo, momento em que também correu. Ao virar a esquina, acabou deparando-se com uma viatura da Polícia Militar e acabou sendo abordado. Os policiais lhe revistaram e acabaram encontrando, em seu bolso, algumas pedras de crack, as quais confirma que estava vendendo pelo valor de R\$ 10,00 cada. Esclarece que pegou o entorpecente de um desconhecido nos "Predinhos" no dia de ontem, à tarde. Que havia combinado de vender o entorpecente e, no dia seguinte, tal rapaz iria buscar o dinheiro das vendas e lhe daria uma parte. Não sabe dizer onde tal pessoa reside. Que o dinheiro encontrado em seu poder era proveniente da venda dos entorpecentes. Que o aparelho celular encontrado em seu poder pertence a sua mãe, nada tendo a ver com os fatos. Que estava sozinho vendendo, não conhecendo o outro indivíduo que foi preso no

local. Que é usuário de maconha e tem passagem anterior por tráfico de drogas, tendo ficado apreendido na Fundação Casa, sendo que saiu a cerca de 25 dias". Em Juízo, confirmou as declarações anteriores, disse também que "estava na biqueira vendendo, a polícia o pegou e falaram que pegaram Augusto, mas não sabe se ele estava vendendo".

O réu AUGUSTO na Delegacia de polícia, permaneceu calado. Em Juízo disse que não é verdadeira a acusação. Falou que "é usuário de cocaína e tinha ido comprar, única coisa que pegaram com ele foram as quatro cocaínas que comprou, as demais drogas os policiais jogaram para cima dele porque as outras pessoas saíram correndo. O dinheiro era o que tinha sobrado de seu pagamento, trabalha em lava-jato".

Diante de todo o conjunto probatório, de rigor a PROCEDÊNCIA da ação penal. Os depoimentos prestados em Juízo pelos policiais que fizeram a abordagem do réu são similares e harmônicos entre si, incluindo aqueles dados na fase administrativa e reduzidos a termos.

O réu não apresentou nada que possa justificar falsa acusação contra ele. Já os policiais militares foram firmes e uníssonos em seus depoimentos. Deram a mesma versão em juízo quando do auto de prisão em flagrante.

Não há qualquer razão para se duvidar do relato dos agentes públicos, que não teriam motivos para acusarem o réu injustamente, sendo seus testemunhos válidos, com o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos, sendo inquestionáveis, até que se prove o contrário, por gozarem de fé pública e quando corroborado com os outros elementos de prova.

A única testemunha arrolada pela defesa, o menor P.H. disse que estava no local vendendo drogas, mas não sabe o que o réu estava fazendo, portanto, nada acrescentou na defesa do réu, apenas confirmando a mercancia no momento da abordagem.

O exame químico-toxicológico (fls.87/89) realizado nos entorpecentes encontrados em poder do réu resultou em positivo para COCAÍNA, substância de uso proscrito no Brasil. Observo que a quantidade da droga e sua forma de acondicionamento demonstra a finalidade diversa do simples uso. Fica afastada, portanto, a tese para uso próprio, sendo irrelevante estar provada a existência de trabalho lícito, visto que a mercancia da droga pode coexistir com ele.

Importante registrar também que é desnecessária a demonstração da comercialização da droga para restar configurado o crime de tráfico de entorpecente.

Isso porque o crime de tráfico é de perigo abstrato, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci: "o tráfico ilícito de entorpecentes... é um crime de perigo (há uma probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado) abstrato (independe de prova dessa probabilidade de dano, pois presumida pelo legislador na construção do tipo)... não se permite ao infrator a prova de que seu comportamento pode ser inofensivo, pois regras de experiência já demonstram à sociedade não ser conveniente à sociedade a circulação de determinadas tipos de drogas". (Leis penais e processuais penais comentadas, 2ª ed. 2007, Editora Revista dos Tribunais, p. 314/315). Ou seja, é punida a conduta pelo risco que ela representa para a saúde pública, portanto, não há necessidade de efetiva prática do ato de comércio da substância entorpecente com a finalidade de venda. Nesse sentido: "APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - TESES DEFENSIVAS: I) DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. II) PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. III) REESTRUTURAÇÃO DA PENA. IV) APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AS TESES DEFENSIVAS NÃO MERECEM ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Demonstrado que o réu guardava a droga e não tendo ele feito qualquer prova da condição de usuário, nem desconstituído as provas existentes em seu desfavor, sendo este um ônus exclusivo da defesa, impõe-se a manutenção da condenação por tráfico. 2. As provas produzidas ao longo da instrução são suficientes para ensejar a condenação do apelante pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, não havendo como acolher a pretendida desclassificação da conduta para a de uso próprio. 3. O tráfico de drogas é delito de perigo abstrato e presumido, criado com o fim de tutelar a saúde e segurança pública, não se restringindo à esfera pessoal do agente, ao contrário, atinge toda a coletividade, vez que estimula outras condutas criminosas, aumentando sobremaneira a violência em nossa sociedade, motivo pelo qual não há que se falar na aplicação do princípio da insignificância. 4.

Inviável o acolhimento da pretendida reestruturação da pena, de acordo com o princípio da proporcionalidade, tendo em vista que já fixada no patamar mínimo legal, após análise escorreita de cada um dos moduladores descritos no art. 59, do CP. 5. Impossível prosperar o pleito de aplicação da atenuante da confissão espontânea no caso em tela, eis que o acusado, na fase policial, silenciou-se e, em juízo, apesar de admitir que a droga era de sua propriedade, alegou que seria destinada ao uso e não ao tráfico, crime este pelo qual restou condenado... O tráfico de drogas é delito de perigo abstrato e presumido, criado com o fim de tutelar a saúde e segurança pública (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Esse delito não se restringe à esfera pessoal do agente, ao contrário, atinge toda a coletividade, vez que estimula outras condutas criminosas, aumentando sobremaneira a violência em nossa sociedade. Daí porque não há que se falar na aplicação do princípio da insignificância.". (Apelação Criminal 1.0480.11.006978-2/001; 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, RELATOR WALTER LUIZ DE MELO; j. 28/08/2012).

Ainda: "TÓXICOS - TRÁFICO - AUTORIA E MATERIALIDADE - PROVA SUFICIENTE - INSIGNIFICÂNCIA - NÃO APLICAÇÃO - NEGATIVA DA AUTORIA ISOLADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - CREDIBILIDADE - COMÉRCIO - DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA - CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE TÓXICOS - REQUISITOS PREENCHIDOS PARA A SUA APLICAÇÃO - FRAÇÃO - MANUTENÇÃO - REGIME PRISIONAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - SUBSTITUIÇÃO DO ART. 44 DO CPB - CABIMENTO NO CASO CONCRETO. - Se, apesar de o réu negar a autoria do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, as provas são aptas a comprovar os fatos havidos na denúncia, correta é a condenação nos termos do art. 33 da Lei 11.343/06. - A pequena quantidade de droga apreendida, por si só, não é suficiente para tornar a conduta atípica, uma vez que o delito de tráfico, enquanto delito de perigo abstrato, apresenta grande lesividade à saúde e à incolumidade pública, o que não pode ser graduado somente pela quantidade de entorpecente apreendida. - Os depoimentos prestados pelos policiais que participaram do flagrante merecem todo o crédito, se são coerentes, firmes e seguros e se contra eles não há qualquer indício de má-fé. - Para a caracterização do delito do art. 33 da Lei n. 11.343/06, crime de ação múltipla, basta a simples posse da droga pelo agente, não exigindo a consumação de qualquer resultado, como a venda ou a efetiva entrega do entorpecente. - É cabível a aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos se o agente é primário, de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa. - A fração de redução de pena prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/06, deve ser fixada de acordo com as regras do art. 59 do CPB daquela norma antidrogas. - Adotando o novo entendimento disposto quando do julgamento de Incidente de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal de Justiça, cabível é a concessão do regime prisional diverso do fechado nos casos de tráfico privilegiado. - Preenchidos os requisitos legais, cabe conceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, mesmo no caso de tráfico de entorpecentes.". (Apelação criminal nº 1.0079.10.610239-9/001, 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, RELATOR CATTÁ PRETA, j. 04/09/2012).

Reconheço a causa de aumento de pena do inciso VI do artigo 40 da Lei 11.343/06, restou demonstrado que o acusado estava na companhia do menor P.H. no momento que comercializava o entorpecente.

Diante de todo o exposto, considero que o réu praticou o crime previsto no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06.

Passo a dosar a pena, lembrando que a pena mínima nesse caso é de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, acrescida de ao menos 1/6. Na aplicação da pena, sopesados os elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal e do art. 62 da Lei de Drogas bem como considerando a certidão às folhas 134, fixo a pena base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pois o réu é primário.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade (Artigo 65, inciso I do Código Penal), que deixo de aplicar porque a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal.

Na terceira fase, presente a majorante prevista no art. 40, VI da lei de drogas.

Houve depoimento seguro dos policiais quanto a circunstância da presença do menor. Assim, a pena sobe em 1/6 para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Presente a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, diante da primariedade e bons antecedentes do réu. Assim reduzo a quem do mínimo, em 2/3, para 01 (um) ano e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

À mingua de outras causas modificadoras da pena, torno a pena acima a pena definitiva.

O regime carcerário será inicialmente o ABERTO, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, sendo o réu primário.

Cada dia multa deverá ser calculado no mínimo legal (um trigésimo do valor do salário-mínimo vigente), diante da ausência de elementos quanto à situação econômica do réu, e o valor deverá ser corrigido no momento da execução. Por fim, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por DUAS penas restritivas de direito consistentes em prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo, sem prejuízo da pena de multa imposta, e prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da condenação.

Em caso de descumprimento do benefício iniciará o cumprimento da pena em regime aberto (artigo 33, § 1º, alínea "c", do Código Penal).

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, por entender incompatível tal estipêndio com o crime apurado, dada a natureza difusa do ofendido.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu AUGUSTO CASAGRANDE PEREIRA DOS SANTOS, como incurso no artigo 33, caput c.c. o artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, e, reconhecido o privilégio do §4º do mesmo dispositivo legal, a cumprir a pena de 01 (um) ano e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, em regime inicial ABERTO. SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por DUAS penas restritivas de direito consistentes em prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo, sem prejuízo da pena de multa imposta, e prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da condenação. As penas pecuniárias deverão ser atualizadas pelos índices de correção monetária no momento da execução, nos termos do artigo 49, §2º do Código Penal.

Determino a destruição dos telefones celulares apreendidos (fls.20), nos termos do artigo 516, § 2º, NSCGJ.

Declaro o perdimento do dinheiro apreendido às folhas 20/21(R\$390,00 apreendido com o réu e R\$ 80,00 apreendido com o menor P.) por ser produto do ato equivalente ao crime de tráfico. Transfira-se a SENAD com as cautelas de praxe.

Por fim, quanto ao entorpecente apreendido (fls.20/21), verifico que já foram destruídos (fls. 114/117).

Custas "ex lege". Aos defensores nomeados, arbitro honorários nos termos do convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a Ordem dos Advogados do Brasil - SP em vigor. Expeça-se certidão.

P.I.C. Com o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Mirassol, 23 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA